

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 25/09/2024
EXAME PRÉVIO DE EDITAL
SEÇÃO ESTADUAL

(E-001)

Processo: TC 017955.989.24-9.

Representante: Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda.

Representada: Secretaria de Gestão e Governo Digital do Estado de São Paulo.

Responsável: Caio Paes de Andrade – Secretário de Estado.

Assunto: Representação que visa ao exame prévio do edital de Credenciamento nº 002/2024, processo administrativo nº 018.00014482/2024-16, promovido pela Secretaria de Gestão e Governo Digital, que tem por objeto o credenciamento, de empresas especializadas na prestação de serviços de fornecimento, gerenciamento, implementação e administração de vale refeição, por meio de cartão eletrônico/magnético ou cartão eletrônico multibenefícios, com chip de segurança e senha individual, aos servidores e empregados públicos em exercício nas unidades da Secretaria de Gestão e Governo Digital, e aos integrantes das carreiras de Especialista em Políticas Públicas de que trata a Lei Complementar nº 1.034/2008.

Valor estimado: R\$ 9.510.336,00 (nove milhões, quinhentos e dez mil e trezentos e trinta e seis reais).

Período de credenciamento: vigência de 10 (dez) anos, permitindo a qualquer tempo a inscrição de novos interessados que atendam às exigências do chamamento público.

Procuradora de Contas: Élidea Graziane Pinto.

Procuradora da Fazenda do Estado: Patrícia Ulson Pizarro Werner.

Advogado habilitado no e-tcesp: Rafael Prudente Carvalho Silva (OAB/SP 288.403)

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. CREDENCIAMENTO. ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE REFEIÇÃO. EXIGÊNCIA DE NÚMERO MÍNIMO DE ADESÕES DE BENEFICIÁRIOS COMO REQUISITO DE CONTRATAÇÃO. IRREGULAR. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DO PROCEDIMENTO AUXILIAR PREVISTO NO ARTIGO 79 DA LEI 14.133/21. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. O credenciamento promovido com base no inciso II do artigo 79 da Lei Federal nº 14.133/21 não permite que o certame licitatório contenha critério de seleção que imponha número mínimo de adesões para a contratação das proponentes habilitadas, pois referida regra configura desvirtuamento da finalidade essencial do credenciamento, que consiste na

seleção de todos os ofertantes que preencham os requisitos necessários para o fornecimento de determinado bem ou serviço, preservada a possibilidade de livre seleção do contratado pelo beneficiário direto da prestação.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA**, apresentada com fundamento no artigo 170, §4º da Lei federal nº 14.133/21, em face do edital de Credenciamento nº 002/2024, processo administrativo nº 018.00014482/2024-16, que tem por objeto o credenciamento, de empresas especializadas na prestação de serviços de fornecimento, gerenciamento, implementação e administração de vale refeição, por meio de cartão eletrônico/magnético ou cartão eletrônico multibenefícios, com chip de segurança e senha individual, aos servidores e empregados públicos em exercício nas unidades da **SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL**, e aos integrantes das carreiras de Especialista em Políticas Públicas de que trata a Lei Complementar nº 1.034/2008.

O edital de credenciamento terá vigência de 10 (dez) anos, permitindo a qualquer tempo a inscrição de novos interessados que atendam às exigências do chamamento público.

1.2. A Representante contestou a imposição de quórum mínimo de adesão como condição para assinatura do contrato¹, sob o argumento de que a

¹ **11.2.** Após a publicação da homologação do resultado, com a lista de credenciados, no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP e no Diário Oficial do Estado - DOE, a qual constituirá o ato de reconhecimento do credenciamento, se reunidos ao menos 79 (setenta e nove) servidores, interessados na adesão ao(s) cartão(ões) disponibilizado(s) pela credenciada, a Secretaria de Gestão e Governo Digital – SGGD, procederá à convocação para formalização do respectivo Contrato, conforme modelo constante do Anexo II – Minuta de Contrato.

referida regra fere a disciplina do artigo 79 da Lei Federal nº 14.133/21, que prevê que toda empresa que for escolhida, independentemente da quantidade de servidores que optarem, deve ser contratada.

Além disso, apontou possível inobservância das regras da Lei 14.442/2022 ao deixar de prever pagamento de forma pré-paga².

1.3. Nestes termos, requereu a Representante que fosse determinada a suspensão cautelar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. Da análise da petição inicial, embora as alegações da Representante demonstrassem a presença de indícios de inobservância da disciplina do artigo 79 da Lei 14.133/21 bem como o preenchimento dos pressupostos da oportunidade, materialidade e relevância para o exame de parte da matéria impugnada por esta Corte, na conformidade do artigo 170 da Nova Lei de Licitações e Contratos, a ausência do *periculum in mora* determinou, a meu ver, o esvaziamento da hipótese de se determinar a suspensão cautelar do procedimento, na forma do §1º do artigo 171 da Lei 14.133/21. Explico:

O ato convocatório impugnado permite a qualquer tempo a inscrição de novos interessados que atendam às exigências do chamamento público, não havendo, como nas licitações convencionais, a previsão de sessão pública de abertura de propostas, disputa de lances e outras etapas do procedimento cuja continuidade prejudicaria a efetividade e utilidade da tutela jurisdicional deste órgão de controle externo.

² **7.22.** Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da nota fiscal ou documento de cobrança equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos do art. 2º, II, do Decreto estadual nº 67.608, de 2023.

Vislumbrei que, no presente caso, o Tribunal de Contas poderia oportunizar o contraditório e a ampla defesa, submeter a representação à análise dos órgãos técnicos e do Ministério Público de Contas e, ao final, definir as medidas eventualmente necessárias e adequadas, em face das alternativas possíveis, para o saneamento do procedimento impugnado. A efetividade e utilidade da decisão que examinar o mérito da insurgência prescindiam da suspensão do credenciamento.

Desta forma, entendi na avaliação inicial da representação que esta poderia ser processada no rito sumaríssimo do artigo 220 e seguintes do RITCESP sem que se determinasse, no entanto, a suspensão cautelar do credenciamento, razão pela qual propus no voto submetido à deliberação do E. Tribunal Pleno na sessão de 25/09/2024 o **INDEFERIMENTO da medida cautelar requerida pela Representante**.

1.5. Além disso, considerando o teor das diretrizes previstas no artigo 170 da Lei federal n. 14.133/21, que impõem na fiscalização dos atos previstos na lei de licitações a adoção **de critérios de materialidade e relevância, e com a finalidade de prestigiar os princípios da economia processual, da segurança jurídica e da celeridade**, próprios desta via processual, o voto aprovado na sessão de 28/08/2024 propôs igualmente o **afastamento, de plano, da cognição da insurgência relativa ao prazo de pagamento ao contratado, disciplinado no ato convocatório**.

A impugnação incidiu sobre questão já decidida por este Tribunal e a representação não trouxe elementos inéditos que justificassem nova avaliação pelos órgãos técnicos que oficiaram nestes autos, de modo que vislumbrei sólidos fundamentos para propor a decretação de sua improcedência.

Isto porque o entendimento contido no voto condutor do julgamento dos TCs 8227.989.23, 8232.989.23, 8333.989.23, 9051.989.23 e 9106.989.23, relatados pelo eminente Conselheiro Robson Marinho na sessão de 10/05/2023, tomou por premissa que o valor correspondente aos repasses dos numerários referentes aos créditos dos cartões dos beneficiários é considerado despesa pública, submetendo-o aos estágios previstos nos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64 (empenho, liquidação e pagamento), inviabilizando portanto sua antecipação à administradora dos benefícios.

A interpretação prevalente naquele julgado em relação ao inciso II do artigo 3º da Lei 14.442/2022 estabelece a produção de efeitos apenas na relação da administradora com os empregados beneficiários, obrigando-a ao repasse dos créditos nos cartões dos beneficiários de forma a garantir a natureza pré-paga do benefício.

No entanto, esta Corte rejeitou o aproveitamento do dispositivo para tutelar a pretensão de antecipação dos pagamentos às empresas administradoras dos cartões de benefícios, por confrontar com a disciplina legal da despesa pública.

Por oportuno, transcrevo a ementa do julgamento do TC 10229.989.23-1 (Tribunal Pleno – sessão de 24/05/2023), de minha relatoria, e que bem sintetiza o entendimento prevalente nesta Corte com relação ao tema:

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO – VALE-ALIMENTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 3º, INCISO II DA LEI 14.442/2022. NATUREZA PRÉ-PAGA DOS VALORES A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS TRABALHADORES. PRETENSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE REPASSES À ADMINISTRADORA. VEDAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS ESTÁGIOS DA DESPESA PÚBLICA – EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 62 E 63 DA LEI 4.320/64. IMPROCEDÊNCIA.

1. Na contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação – vale-alimentação, o valor correspondente aos repasses dos numerários referentes aos créditos dos cartões dos beneficiários é considerado despesa pública, submetendo-o aos estágios previstos nos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64 (empenho, liquidação e pagamento), inviabilizando, portanto, sua antecipação à administradora dos benefícios;
2. A regra do inciso II do artigo 3º da Lei 14.442/2022 estabelece a produção de efeitos apenas na relação da administradora com os empregados beneficiários, obrigando-a ao repasse dos créditos nos cartões dos beneficiários de forma a garantir a natureza pré-paga do benefício.

1.6. Todavia, a partir da ponderação dos critérios de oportunidade, materialidade e relevância, previstos no artigo 170 da Lei 14.133/21, avaliei que **a representação comportaria seu recebimento em parte**, de modo que entendi cabível o processamento do feito para permitir especificamente a análise da impropriedade relativa à imposição de quórum mínimo de adesão como condição para assinatura do contrato³, pois as regras de seleção do ato convocatório, impugnadas na petição inicial, denotaram, a princípio, possível desvirtuamento das finalidades do procedimento auxiliar disciplinado no artigo 79 da Lei 14.133/21, que prevê a seleção de todos os particulares que preencham os requisitos necessários para o fornecimento de determinado bem ou serviço, sem a imposição de adesão mínima.

Por esta razão, a matéria foi submetida ao E. Tribunal Pleno na sessão de 28/08/2024, ocasião em que, face à ausência do *periculum in mora* e diante da materialidade da insurgência apresentada, com fundamento nos artigos 170 e 171 da Lei Federal nº 14.133/21, **foi INDEFERIDA a medida cautelar requerida na petição inicial, sem prejuízo do processamento da**

³ **11.2.** Após a publicação da homologação do resultado, com a lista de credenciados, no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP e no Diário Oficial do Estado - DOE, a qual constituirá o ato de reconhecimento do credenciamento, se reunidos ao menos 79 (setenta e nove) servidores, interessados na adesão ao(s) cartão(ões) disponibilizado(s) pela credenciada, a Secretaria de Gestão e Governo Digital – SGGD, procederá à convocação para formalização do respectivo Contrato, conforme modelo constante do Anexo II – Minuta de Contrato.

representação no rito do artigo 220 e seguintes do Regimento Interno para permitir especificamente a análise da impropriedade relativa à imposição de quórum mínimo de adesão como condição para assinatura do contrato, fixando-se o prazo de **10 (dez) dias úteis** para a **SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL** apresentar as alegações julgadas cabíveis em relação à impugnação incidente sobre o texto da cláusula 11.2 do ato convocatório, juntamente com os demais elementos relacionados com o certame em questão, requisitados nos termos do artigo 171, § 2º da Lei nº 14.133/21.

1.7. Notificada, a Secretaria Representada apresentou justificativas e alegações por meio das quais sustentou a conformidade do ato convocatório, salientando o atendimento ao artigo 11, II e artigo 79, II e Parágrafo único, inciso III da Lei Federal nº 14.133/21.

Argumentou, em suma, que: i) o direito de livre seleção do contratado pelo beneficiário direto da prestação está preservado e garantido; ii) a homologação, pela autoridade competente, da lista de credenciados é o ato administrativo que reconhece o credenciamento de todos os interessados, habilitados pela comissão de credenciamento, sem qualquer condicionante, observadas a regras de habilitação; iii) o quantitativo de 79 servidores indicado na cláusula 11.2 se refere a momento posterior as fases de Credenciamento e da seleção das empresas pelos beneficiários diretos, momento este, no qual permanecem atendidos os preceitos da Lei 14.133/21.

E afirmou que o referido quantitativo se insere na discricionariedade de seleção/eleição pelos beneficiários e representa o percentual de 10% (dez por cento) do total estimado de cartões objeto do credenciamento (evento 27).

1.8. A **Unidade Jurídica da Assessoria Técnico-Jurídica**, com endosso da respectiva **Chefia de ATJ**, concluiu no sentido da **procedência parcial** da Representação (evento 40), com entendimento que considerou

prosperar a impugnação contra a imposição de quórum mínimo de adesão para que seja efetivada a contratação.

Além de ter consignado que o edital em questão destoava das regras do artigo 79 da Lei Federal nº 14.133/2021, salientou que outro aspecto marcante desse procedimento, além das condições legais de contratação, é a pluralidade de credenciados e a coexistência de múltiplas empresas contratadas, vez que o sistema de credenciamento tem como uma de suas bases a contratação de todos os interessados que preencham as condições estabelecidas pela administração pública.

1.9. A **D. Procuradoria da Fazenda do Estado** (evento 43), por sua vez, se pronunciou pela **improcedência** da representação, consignando que “o quantitativo fixado corresponde a 10% do total da contratação, valor referencial para fins de cálculo da admissão do credenciamento de prestador para um número de servidores menor do que esse poderia gerar maiores custos operacionais e administrativos, atentando a vantajosidade genericamente considerada”.

1.10. O **d. Ministério Público de Contas** (evento 48) emitiu parecer no sentido da **procedência** da questão alusiva à **imposição de quórum mínimo de adesão como condição para assinatura do contrato**, sustentando que o edital cria condição não prevista no artigo 79 da Lei 14.133/21, e desvirtua a finalidade essencial do credenciamento “com seleção a critério de terceiros”, qual seja, a seleção do contratado pelo beneficiário direto da prestação, de acordo com as suas preferências individuais.

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO
EXAME PRÉVIO DE EDITAL

SESSÃO: 25/09/2024
TC-017955/989/24-9

SEÇÃO ESTADUAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representação de **MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA**, apresentada com fundamento no artigo 170, §4º da Lei federal nº 14.133/21, em face do edital de Credenciamento nº 002/2024, processo administrativo nº 018.00014482/2024-16, que tem por objeto o credenciamento, de empresas especializadas na prestação de serviços de fornecimento, gerenciamento, implementação e administração de vale refeição, por meio de cartão eletrônico/magnético ou cartão eletrônico multibenefícios, com chip de segurança e senha individual, aos servidores e empregados públicos em exercício nas unidades da **SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL**, e aos integrantes das carreiras de Especialista em Políticas Públicas de que trata a Lei Complementar nº 1.034/2008.

2.2. Inicialmente, registro que, com fundamento nas diretrizes previstas no artigo 170 da Lei federal n. 14.133/21, que impõem na fiscalização dos atos previstos na lei de licitações a adoção de critérios de materialidade e relevância, e com a finalidade de prestigiar os princípios da economia processual, da segurança jurídica e da celeridade, próprios desta via processual, a insurgência relativa à disciplina do prazo de pagamento ao contratado teve sua cognição afastada consoante deliberação do E. Tribunal

Pleno na sessão de 28/08/2024 com o reconhecimento, de plano, de sua improcedência.

A impugnação incidiu sobre questão já decidida por este Tribunal e a representação não trouxe elementos inéditos que justificassem nova avaliação pelos órgãos técnicos que oficiaram nestes autos.

2.3. A representação foi recebida em parte, especificamente para permitir a análise da impropriedade relativa à imposição de quórum mínimo de adesão como condição para assinatura do contrato⁴, que considero **procedente**, na mesma linha de entendimento contida nos pareceres da Assessoria Técnico-Jurídica e do D. Ministério Público de Contas.

O procedimento em análise, por um lado, atende ao que dispõe o inciso I do Parágrafo único do artigo 79, que determina que a Administração permita o cadastramento permanente de novos interessados, porém, erra ao não contemplar plenamente o interesse de livre escolha individual dos servidores ao impor que a credenciada acumule a adesão mínima de 10% do contingente de beneficiários para ter direito à contratação.

Não é possível permitir que um procedimento de credenciamento fundado no artigo 79 da Lei Federal nº 14.133/21 tenha prosseguimento com um critério de seleção que impede a contratação de todos os interessados que preencham as condições estabelecidas pela Administração e que deixa de prestigiar as preferências individuais dos beneficiários.

⁴ **11.2.** Após a publicação da homologação do resultado, com a lista de credenciados, no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP e no Diário Oficial do Estado - DOE, a qual constituirá o ato de reconhecimento do credenciamento, se reunidos ao menos 79 (setenta e nove) servidores, interessados na adesão ao(s) cartão(ões) disponibilizado(s) pela credenciada, a Secretaria de Gestão e Governo Digital – SGGD, procederá à convocação para formalização do respectivo Contrato, conforme modelo constante do Anexo II – Minuta de Contrato.

Considero, neste panorama, inconsistentes as alegações de que os custos operacionais e administrativos decorrentes da eventual contratação de todos os particulares que preencham os requisitos necessários para tanto ocasionaria a perda da vantajosidade, pois a pluralidade de prestadores de serviços e a elevação desse quantitativo no prazo de vigência do edital é da própria natureza do instituto do credenciamento, como destacado no parecer da Assessoria Técnico-Jurídica.

Vale registrar que o artigo 6º, XLIII, da Lei nº 14.133/21 define o credenciamento como *“processo administrativo de chamamento público em que a Administração Pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados”*.

Além destes aspectos, a regra impugnada não possui previsão na Lei Federal nº 14.133/21 e extrapola o que poderia ser objeto de regulamento específico, na forma do §1º do artigo 79 da Nova Lei de Licitações e Contratos, dado o caráter restritivo que lhe é inerente.

2.4. Ante todo o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da representação e, com fundamento no §3º do artigo 171 da Lei 14.133/21, determino à **SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL** que exclua do credenciamento a cláusula que impõe número mínimo de adesões como condição para assinatura do contrato, imprimindo integral atendimento ao artigo 79 da Lei Federal nº 14.133/21.

A retificação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente divulgação do novo texto, para os devidos fins e efeitos de Direito.

Por fim, após o trânsito em julgado, archive-se o procedimento eletrônico.

Dimas Ramalho
Conselheiro